

第2節 実行行為

刑法

No13

H21-4

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、日ごろから暴行を加えて自己の意のままに従わせていた12歳の乙に対し、寺院のさい銭箱から現金を盗んでくるように指示したところ、乙は、是非善悪の判断能力を有していたものの、甲の日ごろの言動に畏怖してその意思が抑圧されていたため、甲の指示どおりに窃盗を行った。この場合、乙には是非善悪の判断能力があると認められる以上、甲には窃盗罪の共同正犯が成立する。
2. 甲は、乙所有の材木を自己の所有物であると偽って情を知らない丙に売却し、丙は、乙の材木置場から当該材木を搬出した。この場合、情を知らないことにつき丙に過失があったとしても、甲は窃盗罪の正犯となる。
3. 甲は、12歳の乙に対し、丙から現金を強取してくるように指示したところ、乙は、是非善悪の判断能力を有していたものの、甲の指示どおりに強盗を実行した。この場合、甲の指示は、乙の意思を抑圧するに足る程度のもではなく、乙が自らの意思により前記強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を遂げたとしても、乙が刑事未成年である以上は、甲には強盗罪の間接正犯が成立する。
4. 甲は、乙に執拗に暴行・脅迫を加えた結果、同人を厳冬期に漁港の岸壁から自動車ごと海中に転落して自殺する以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせた上、同人に上記態様で自殺するよう指示し、乙は、甲の指示に従って、自殺することを決意し、自ら上記態様で海中に転落して溺死した。この場合、甲は自ら殺人の実行行為を行ったとはいえないので、殺人罪の正犯とならない。
5. 甲は、乙に対し、同人が自殺すれば甲もその直後に後を追って自殺する旨うそをつき、乙は、その旨誤信して自殺することを決意し、甲から受け取った毒薬を服用して死亡した。この場合、乙に真実自殺する意思がある以上、甲には自殺教唆罪が成立するにとどまり、殺人罪の正犯とならない。

1 誤っている

最決昭 58.9.21 (百選 I 74 事件)。本記述では、被利用者が是非善悪の判断能力を有している場合に、利用者に共同正犯が成立するかが問題となる。この点、本記述と同様の事案において、判例は、「同女が是非善悪の判断能力を有する者であったとしても……窃盗の間接正犯が成立する」としている。その理由として、判例は、「日頃……暴力を加えて自己の意のままに従わせ……自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して右各窃盗を行ったと認められる」ということを挙げている。よって、本記述における甲には窃盗罪の間接正犯が成立し得る。したがって、本記述は、乙に是非善悪の判断能力があると認められる以上、甲には窃盗罪の共同正犯が成立するとしている点で、誤っている。

2 正しい

最決昭 31.7.3。本記述では、過失により事情を知らない買主を利用した場合に、売主が窃盗罪の正犯となるかが問題となる。この点、採炭運搬のために据えつけたドラグライン一基を、屑鉄として自己に処分権があるかのように装って売却し、情を知らない買主が、古鉄回収業者に搬出させたという事案において、判例は、売主は、「窃盗罪の刑事責任を免れることはできない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者が、構成要件の結果について故意のない媒介者の行為を介入させた場合には、媒介者を「道具のように」利用して構成要件を実現したと見ることができるということを挙げている。よって、本記述における甲は窃盗罪の正犯となる。

3 誤っている

最決平 13.10.25 (重判平 13 刑 4 事件)。本記述では、被利用者が自らの意思により強盗を遂げた場合に、利用者が強盗罪の間接正犯となるかが問題となる。この点、本記述と同様の事案において、判例は、「本件当時Bには是非弁別的能力があり、被告人の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のもではなく、Bは自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなど……の事情に照らすと……間接正犯が成立するものとは、認められない」「被告人は……本件強盗を計画し、Bに対し犯行方法を教示するとともに犯行道具を与えるなどして本件強盗の実行を指示命令した上、Bが奪ってきた金品をすべて自ら領得したことなどからすると……教唆犯ではなく共同正犯が成立する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被利用者には是非弁別的能力があり、被利用者自身の意思で強盗を決意したのであって、指示の態様が「実質的に支配している」とまではいえないということを挙げている。よって、本記述における甲には強盗罪の間接正犯は成立しない。したがって、本記述は、乙が刑事未成年である以上は、甲には強盗罪の間接正犯が成立するとしている点で、誤っている。

4 誤っている

最決平 16.1.20 (百選 I 73 事件)。本記述では、被害者自身の行為を利用した場合、利用者が殺人罪の正犯となるかが問題となる。この点、利用者の指示通り被害者が海中に飛び込んだが、助かったという事案において、判例は、「被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たる」とし、結論として、「殺人未遂罪に当たる」としている。その理由として、判例は、「本件犯行当時、被害者をして、被告人の命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたものといえることができる。被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ぼせたものである」ということを挙げている。よって、本記述に

おける甲は、自ら殺人の実行行為を行ったとして、殺人罪の正犯となる。したがって、本記述は、甲は殺人罪の正犯とならないとしている点で、誤っている。

5 誤っている

最判昭 33.11.21（百選Ⅱ 1 事件）。本記述では、被害者の錯誤を利用した場合において、利用者に自殺教唆罪が成立するにとどまるか、殺人罪の正犯が成立するかが問題となる。この点、本記述と同様の事案において、判例は、「通常の殺人罪に該当する」としている。その理由として、判例は、「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである」とし、同意が「被害者の自由な真意に基づかない場合は刑法 202 条にいう被殺者の嘱託承諾としては認め得られない」ということを挙げている。よって、本記述における甲は殺人罪の正犯となる。したがって、本記述は、甲には自殺教唆罪が成立するにとどまり、殺人罪の正犯とならないとしている点で、誤っている。